

1516323-84.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; quanto à dosimetria da pena, aplicação do disposto no artigo 68, do Código Penal, ante a existências de duas qualificadoras no crime de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). Por fim, requereu a concessão da gratuidade da Justiça ao réu, afastando-se a incidência da pena de multa.

É o relatório do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516323-84.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516323-84.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO ARAUJO QUITERIA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

ANTONIO ARAUJO QUITERIA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, h, e artigo 158, §1º e 3º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque teria, no dia 1º de maio de 2022, por volta das 19h, na Avenida das Nações Unidas, nº 16741, Vila Gertrudes, nesta cidade e comarca da capital, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bem como com restrição da liberdade das vítimas Fábio Luis Stamatis, e suas filhas, crianças, Manuela e Grabiela, teria subtraído, para ambos, 2 (dois) celulares da marca Apple, modelo Iphone, avaliados em R\$3.500,00 (três) mil e quinhentos reais cada, e 1 (um) cartão de crédito, bens pertencentes à vítima Fábio.

Consta, ainda na denúncia que, no dia 01 de maio de 2022, por volta de 20h, Rua Itangá, n. 33 (Botequim dos Caldos e Petiscos), Paraísoópolis, nesta cidade e

comarca da capital, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria constrangido Fábio Luis Stamatis, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem assim com restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para obter indevida vantagem econômica para proveito próprio, a passar o cartão bancário subtraído em estabelecimento comercial, auferindo-se, assim, vantagem de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Segundo consta na denúncia ANTONIO e o outro comparsa foram até o supermercado Extra do Morumbi e, ao avistarem a vítima no estacionamento colocando as compras no porta-malas, resolveram abordá-la. A vítima estava com suas filhas, duas crianças, uma de sete, outra de quatro anos de idade.

O acusado então, com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e obrigou a vítima e as filhas a entrarem no veículo. Em ato contínuo, o acusado e o comparsa exigiram que a vítima dirigisse até Paraisópolis, onde procuraram um caixa eletrônico, mas não encontraram. Em seguida o acusado e o outro indivíduo determinaram que a vítima parasse o carro no estabelecimento "Botequim dos Caldos" e lá passaram a exigir que Fábio passasse seu cartão de crédito no valor de R\$3.000,00. As crianças ficaram no interior do veículo em poder de um dos roubadores, para que a vítima Fábio pudesse adentrar o estabelecimento e fazer a transação espúria.

Após saírem do local, ainda rodaram com a vítima e as filhas na comunidade durante um tempo até liberá-las, não sem antes subtrair o cartão de crédito e dois telefones celulares da vítima.

Após, os roubadores ainda fizeram uma compra no valor de R\$460,00, com o cartão de crédito subtraído da vítima.

Posteriormente, foram encetadas investigações por policiais civis, que diligenciaram no bar indicado pela vítima, e no local conversaram com Francisco, proprietário do estabelecimento, que relatou o ocorrido e reconheceu a vítima e ANTONIO como sendo uma das pessoas que esteve em seu bar e passou o cartão de crédito na máquina, na data dos fatos.

Com a identificação de ANTONIO, a vítima o reconheceu via fotografia (cf. auto de reconhecimento a fls. 03) e após a decretação da prisão temporária do denunciado nos autos nº 1516369-73.2022.8.26.0050, ele foi capturado (fls. 16) e reconhecido pessoalmente por Fábio como sendo a pessoa que, empregando arma de fogo, subjugou-a (cf. auto de reconhecimento a fls. 24).

O réu foi preso em razão de decreto de prisão temporária, tendo sido sua prisão sido convertida em prisão preventiva (fls. 51/54).

A denúncia foi oferecida às fls. 35/39, tendo sido recebida às fls. 71/72.

O réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 91/94) por meio de advogado constituído (procuração a fls. 57), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 98).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Fábio Luis Stamatis e os depoimentos das testemunhas Francisco Carlos Camelo Rocha, Andreia Maria Silveira e Renan Henrique Cosmo de Oliveira, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público (fls. 115/124) a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, notadamente ante a prova oral e documental coligida aos autos, Quanto à dosimetria da pena, requereu aumento da pena-base diante do reconhecimento das circunstâncias mais gravosas em que os delitos foram praticados, reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", vez que o delito foi cometido contra crianças e, por fim, fixação de regime prisional fechado para desconto da reprimenda.

Já, a Defesa, por primeiro, alegou a nulidade do reconhecimento realizado em Juízo e, na fase policial, por inobservância das disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Eventualmente, superada a preliminar, no mérito pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E, por fim, em caso de condenação, o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis, absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; quanto à dosimetria da pena, aplicação do disposto no artigo 68, do Código Penal, ante a existências de duas

qualificadoras no crime de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). Por fim, requereu a concessão da gratuidade da Justiça ao réu, afastando-se a incidência da pena de multa.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. A preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em Juízo, assim como durante a fase policial, não merece guarida, vez que, nos termos do que dispõe o artigo 226, "caput", do Código Penal, as disposições ali insertas devem ser observadas sempre que possível.

No caso em tela, todas as cautelas legais foram adotadas no reconhecimento judicial, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato ou, mesmo necessidade de realização de qualquer diligências suplementar.

Inexistindo outras questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), relatório de investigações (fls. 09/10), documentos (fls. 11,13) além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu, na fase policial, exerceu o direito constitucional de ficar calado (fls. 21).

Ouvido em Juízo, afirmou ser solteiro, sem filhos, ser pessoa de pouca instrução escolar formal, viciado apenas em cigarros, trabalhar como gesseiro. Negou os fatos narrados na denúncia e, alega que não sabe porque seu nome foi envolvido neste crime. Sequer mora na comunidade de Paraisópolis.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, Fabio Luis Stamatis, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "no dia 01/05/2022, domingo, às 19 h, foi vítima de sequestro relâmpago ocorrido no estacionamento do supermercado Extra Morumbi, no bairro Panambi. Conta-nos que estava guardando as compras em seu carro, ainda no estacionamento do supermercado, na companhia de suas duas filhas, Manuela e Gabriela uma de sete anos de idade e outra de quatro anos, quando foi surpreendido por dois homens que na posse de uma arma de fogo anunciaram assalto. Disseram para o declarante entrar no veículo e dirigir, pois precisavam de uma carona e teria que ser rápido. Que deixou o carrinho das compras no estacionamento. Que obedeceu à ordem dos indivíduos e eles mandaram ir para a comunidade Paraisópolis. Que os indivíduos fizeram a vítima rodar e procurar um caixa eletrônico para retirar dinheiro, no entanto, não encontraram. Que eles então decidiram ir até um bar onde exigiram que a vítima passasse o cartão de crédito o valor de R\$ 3.000,00 reais em um bar que fica na Rua Intanga nº33- Paraisópolis - Botequim dos Caldos, enquanto um deles ficou no veículo com suas duas filhas. Que os indivíduos roubaram dois celulares, Iphone XR e Iphone 6S. Que rodaram pela comunidade e após um tempo, os indivíduos liberaram as vítimas, porém, subtraíram o cartão de crédito que tem a compra efetuada por aproximação e logo que a vítima saiu eles fizeram uma compra no valor R\$ 460,00 reais. Informa que tem capacidade de reconhecer os infratores".

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento anterior, afirmando que no dia dos fatos tinha ido ao supermercado (como era de hábito) na companhia de suas duas filhas (de sete e de quatro anos). Realizadas as compras, dirigiram-se ao estacionamento quando veio a ser abordado por dois homens, um deles armado. De

imediatamente, já mandaram a vítima ingressar em seu veículo e o réu ocupou o banco do passageiro, momento em que o comparsa que ingressou no banco traseiro, passou para o réu a posse da arma de fogo e, este o ameaçou constantemente de morte. A vítima tentou se dirigir para a Marginal, porém os meliantes mandaram que a mesma fosse na direção da Comunidade Paraisópolis. Disse que rodaram por muito tempo com o carro a fim encontrarem um lugar para realização de saques bancários, apesar das filhas da vítima chorarem muito dentro do carro, pois estavam todos apavorados. Aí pararam num bar, de propriedade da testemunha Francisco e, mandaram a vítima sair do veículo na companhia do réu, enquanto o comparsa permaneceu no interior do veículo da vítima, com suas duas filhas pequenas. Quando ingressaram no estabelecimento comercial, a vítima recebeu ordem de passar seu cartão, retirando-se de sua conta a quantia de R\$3.000,00 (três mil reais). Após realizado o saque, os assaltantes mandaram que a vítima retornasse para seu veículo, exigindo que novos saques fossem realizados. A vítima não sabe ao certo o que ocorreu, pois, após circularem por mais algum tempo, os dois assaltantes saíram do veículo e se evadiram do local. Após estes fatos, a vítima retornou para sua casa e, no ato de lavratura do Boletim de Ocorrência disse aos policiais civis que sabia exatamente qual era o bar onde tinha sido levado pelos assaltantes, além de fornecer as características físicas deles. Salientou também que permaneceu em poder dos assaltantes por aproximadamente três horas. Após investigação foi chamado ao Distrito Policial, onde reconheceu o réu tanto por fotografia, quanto pessoalmente. Salienta que, durante o reconhecimento por fotografia, várias fotografias lhe foram apresentadas e, durante o reconhecimento pessoal o réu não estava sozinho em sala própria. Ressaltou também que não era o irmão do réu ("Zé Quitéria") que estava junto com ele no momento do assalto.

Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 03 e 24), bem como durante a audiência de instrução e julgamento, com observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal (réu número "2" na cena do reconhecimento).

A testemunha FRANCISCO CARLOS CAMELO ROCHA (fls. 14), em fase policial afirmou "ser proprietário de bar com endereço em Rua Itanga, 1875 - Paraisópolis - botequim dos Caldos. Que na data de 01/05/2022, domingo, por volta de 20:00, o irmão do Zé Quitéria foi até o bar pedindo para que o declarante passasse um cartão na máquina do estabelecimento para poder pegar o valor em dinheiro com o declarante. Que de imediato negou, porém, após insistência, aceitou; ato contínuo o irmão do Zé saiu do bar, retornando em seguida com dois indivíduos desconhecidos, onde um deles sacou o cartão de crédito e faturou na máquina de cartões R\$ 3.000, indo todos embora logo em seguida. Posteriormente retornou o irmão de Zé e o terceiro indivíduo que estava no bar, momento em que o declarante entregou a importância de R\$ 600, bem como acabaram por consumir R\$ 600 em mercadoria do local, entre bebidas, comida e jogos nas máquinas caça-níqueis. Que no dia seguinte, por volta de 17:00 o próprio Zé Quitéria foi até o bar para buscar o restante do valor, retirando a importância de R\$ 1800. Que não fazia ideia de que o cartão utilizado em seu estabelecimento seria de uma vítima que estava sequestrada. Que a pessoa que digitou a senha do cartão na data dos fatos aparentava estar assustada. Que ao lhe ser apresentada fotografia de FABIO LUIS STAMATIS afirma ser a pessoa que digitou a senha do cartão, a qual aparentava estar assustada. Que ao lhe ser apresentada fotografia de Jose Quitéria Araujo, o reconhece como a pessoa de alcunha Ze Quitéria, ao lhe ser apresentada fotografia de Antonio Araujo Quitéria, o reconhece como sendo o irmão de Zé Quitéria, o qual solicitou que passasse o cartão na máquina do estabelecimento, bem como retornou com o dono do cartão para digitar a senha".

Em juízo, afirmou que certo dia, uma pessoa usando o nome de seu conhecido "Zé Quitéria" passou em seu bar e pediu para que, em data próxima, usassem sua máquina de cartão de crédito para pagamento de uma dívida ao irmão dele. E, no dia 1º de maio, pessoas retornaram ao seu estabelecimento comercial, novamente usando o nome de "Zé Quitéria" e efetivamente passaram um cartão de crédito no valor de R\$3.000,00 (três mil reais). Logo depois, retornaram ao seu bar, esta pessoa cujo nome desconhece e queria confirmar se o cartão tinha realmente passado e, no valor indicado. Como a quantia é muito elevada e, os comerciantes só recebem o crédito

depois de trinta dias, disse que eles teriam que aguardar, porém, inconformados, novamente estiveram em seu estabelecimento comercial, pegaram um pouco do dinheiro que a testemunha Francisco tinha no caixa e completaram levando mais alguns mantimentos. No dia seguinte, novamente, o irmão de Zé retornou ao bar, uma terceira vez e, pegou mais um pouco de dinheiro, por conta do crédito de R\$3.000,00 (três mil reais). Frisou a testemunha que, após prestar seu depoimento no Distrito Policial, a mesma pessoa que o procurou retornou novamente em seu bar, exigindo que seu depoimento fosse retificado, a fim de dizer que não conhecia a pessoa do réu e, quem esteve no bar, na companhia da vítima, foi pessoal conhecida pela alcunha de "Bahia". Disse também que o réu frequenta muito pouco seu estabelecimento comercial, mas, não era a primeira vez que pediam para "passar cartão de terceiros".

Os dois policiais civis, Renan Henrique Cosmo de Oliveira e Andreia Maria Silveira, ouvidos durante audiência, confirmaram que receberam Boletim de Ocorrência envolvendo caso de roubo e extorsão mediante sequestro, com indicação do nome de um bar, onde a vítima teria realizado saque em suas contas. Diante desta pista, conversaram com o dono do estabelecimento comercial e, este apenas falou que quem esteve lá com a vítima utilizando a máquina do cartão de crédito era o "irmão do Zé Quitéria". Com esta nova informação, junto ao sistema policial obtiveram as fotos dos irmãos de José Quitéria. Daí, a testemunha Francisco compareceu no Distrito Policial e, reconheceu positivamente o réu como a pessoa que esteve lá e passou o cartão da vítima, no valor de R\$3.000,00 (três mil reais). Salientaram que, a vítima ficou muito comovida ao ver a pessoa do réu durante o reconhecimento no Distrito Policial.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da investigação foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da investigação, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa. Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. De plano, observo que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente (Jurisprudência em Teses, edição 51).

No caso concreto, o réu e seu comparsa constrangeram a vítima a dirigir até a Comunidade Paraisópolis em busca de um caixa eletrônico. Como não encontraram, constrangeram a vítima a digitar sua senha na máquina de cartão de crédito no estabelecimento "Botequim dos Caldos", passando o valor de R\$ 3.000,00, mantendo as filhas da vítima como reféns no interior do veículo dela, sempre acompanhadas do outro comparsa do réu.

Após, o réu e seu comparsa subtraíram dois aparelhos celulares da vítima e seu cartão bancário, fazendo ainda uma compra no valor de R\$ 460,00 com o cartão subtraído.

Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantem-se incólume o concurso material. Ainda mais, no caso em tela, onde o assalto começou no estacionamento do supermercado Extra do Morumbi, a vítima foi obrigada a dirigir até a Comunidade Paraisópolis, onde foi constrangida a passar seu cartão, no valor de R\$3.000,00. Posteriormente, foi obrigada a continuar a dirigir pela comunidade, quando então os roubadores levaram seus bens pessoais e se evadiram do local e, por fim, ainda fizeram mais uma compra com seu cartão de crédito, no valor de R\$460,00. Nesse sentido:

"Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem 'crimes da mesma

espécie'. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do nexo de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente ao concurso material" (STF HC 71.174, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, Primeira Turma. No mesmo sentido: RHC 112.676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012).

O caso é, portanto, de concurso material de crimes.

Nesse caminho, o STF:

"Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão e vice-versa" (RHC 112.676-MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.08.2012).

Em relação ao crime de roubo, de se reconhecer a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal. A narrativa do ofendido é clara, tendo afirmado, ao final de seu depoimento que, acredita ter permanecido por aproximadamente três horas em poder dos assaltantes. Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade da vítima pelo agente, que a manteve em seu poder por período juridicamente relevante, incide a majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP (neste sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.20005).

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. A vítima foi clara ao dizer que o acusado estava armado e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

No caso em comento, é de se observar que além das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (afastando-se a incidência do artigo 68, do Código Penal), visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.

Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser

utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

É certo também que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Em relação ao crime de extorsão, houve restrição da liberdade da vítima e de suas filhas menores, e essa condição foi necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Destaque-se que a causa de aumento do §1º, relativa tanto ao concurso de pessoas como emprego de arma deve ser considerada, ainda que se reconheça a forma qualificada.

Neste sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE.

1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito.

3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena.

4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa.

5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n.

1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.

6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos

acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP.

7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

8. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP).

9. Recurso especial provido.

(REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Repise-se que não há que se falar em "bis in idem", quanto à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V e o delito autônomo tipificado no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, pois tratam-se, pois, de dois delitos autônomos, com unidades de desígnios independentes, como já assentado alhures.

O crime de extorsão trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra a vítima. Consumado, portanto.

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito das negativas do réu durante seu interrogatório judicial, corroborado pela narrativa pormenorizada da vítima, assim como o reconhecimento firme e seguro do réu, tanto perante Autoridade Policial (reconhecimento pessoal e fotográfico), quanto em Juízo (reconhecimento pessoal), além dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Frise-se que, não há que se falar em nulidade por falha no reconhecimento pessoal do réu.

Como restou informado nos autos, a partir das características físicas e também do local onde o cartão de crédito da vítima foi utilizado, chegou-se à pessoa do acusado. A partir daí, por primeiro, procedeu-se ao reconhecimento, apresentando algumas fotografias à vítima e, depois, ao reconhecimento pessoal (com três pessoas, a teor do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal), ainda em solo policial. E, por fim, em Juízo, a vítima reconheceu, mais uma vez, a pessoa do réu, com segurança. E, só assim poderia ser, haja vista ter permanecido por mais de três horas em sua companhia no dia do delito.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 157 e 158, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que nenhuma delas destoa do ordinário. Trata-se de réu primário como se depreende da FA e certidão de fls. 81 e 97.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e; 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para a extorsão qualificada.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea "h", do Código Penal, visto que praticou o crime restringindo a liberdade de duas crianças, aumentando-se a pena de 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de roubo e; 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para a extorsão qualificada.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento, como já

assentado na fundamentação.

Em relação ao crime de extorsão, será aplicado o aumento de 2/5 (dois quintos), tendo em vista que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e por duas pessoas, sendo certo que ambas as circunstâncias foram determinantes para o êxito da ação. Isto porque, durante a extorsão, quando a vítima foi constrangida a digitar sua senha do cartão de crédito dentro de um bar no interior da Comunidade Paraisópolis, um dos comparsas manteve suas duas filhas sob a mira de arma, o que impossibilitou qualquer reação ou pedido de socorro da vítima.

Em relação ao crime de roubo, como já exposto na fundamentação, será aplicada a causa de aumento de 2/5 (dois quintos), em relação às majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, e em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo, de forma sucessiva, pelas mesmas razões acima expostas, todas as causas de aumento foram determinantes para que tivessem sucesso em sua empreitada criminosa, tendo o réu e seu comparsa mantido a vítima e suas duas filhas crianças sob ameaça, com o emprego de arma, tendo feito a vítima rodar por tempo relevante pela comunidade.

Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa em relação ao crime de extorsão qualificada e; 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa em relação ao roubo majorado.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, e somam-se as penas pecuniárias (CP, art. 72), resultando em 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º do Código Penal.

Considerando-se que não ficou preso cautelarmente por tempo suficiente para eventual alteração de regime em caso de aplicação da detração, não incide o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, pelo quantum de pena aplicada e por se tratar de crime com violência ou grave ameaça o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu ANTONIO ARAUJO QUITERIA, CPF 964.944.413-00, RG 38.046.708-2, por infração aos artigos 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", e artigo 158, §1º e 3º, c.c. artigo 61, inciso II, h do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.
Publicada pela liberação nos autos digitais.
Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.
São Paulo, 24 de outubro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA